TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., septiembre dos (02) de dos mil veinte (2020).
(Discutido en Salas 20, 21 y 22 del 31/07, 14/08 y 21/08 de 2020)

Decide el Tribunal -en Sala dual- el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido en marzo 24 de marzo de 2020 por la Magistrada Ponente[1].

I.- ANTECEDENTES

1.- Mediante el proveído cuestionado se efectuó un control oficioso de legalidad respecto del auto proferido en enero 22 del año en curso, para concluir que el recurso propuesto contra la sentencia de primera instancia resultaba improcedente dada su inapelabilidad; por tanto, se dejó sin valor ni efecto el primero y, como consecuencia, inadmitió el medio impugnativo.

Para arribar a tal determinación, la Magistrada expuso con sustento en precedentes jurisprudenciales -emitidos en sede de tutela- que las acciones judiciales derivadas del proceso de Ley 1116 de 2006 -de la que no escapa la prevista en su artículo 61-, son accesorias a ese trámite de recuperación empresarial y, por tanto, son de única instancia por gozar de tal carácter el asunto principal.

2.- Inconforme con dicha determinación, fue recurrida por el extremo actor por la vía del recurso de súplica. Estimó que los precedentes en que se basó la tesis criticada no resultan aplicables al *sub examine* por atender a otro tipo de acciones que difieren de la de responsabilidad de las controlantes o matriz frente al estado de situación concursal de la subordinada, siendo entonces un caso de disanalogía; por tanto, al tenor del artículo 61 de la Ley 1116, a este tipo de actuaciones ha de impartírsele el trámite del proceso abreviado, lo que implica la apelabilidad de la sentencia.

III.- CONSIDERACIONES

3.- El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador

[1] *Magistrda Dra. Clara Inés Márquez Bulla.*

en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto (art. 331 CGP), así como también contra el proveído que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y, contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación.

4.- Sea lo primero advertir que, si bien el auto cuestionado, en principio, atiende a un control oficioso de legalidad, es incuestionable que su natural consecuencia fue la inadmisión del recurso de apelación propuesto contra la sentencia que definió en primer grado el asunto, por tanto la censura, en términos generales, discute la competencia del Tribunal para conocer ese recurso, aspecto que, a luz del precitado artículo 331 del CGP, torna viable su revisión por la Sala Dual, debiendo manifestarse desde ya, que la decisión será revocada por las razones que entran a explicarse:

4.1.- El principio de la doble instancia constituye un elemento integrador del debido proceso, ligado a los derechos de defensa y de contradicción, en la medida que posibilita el ejercicio de defensa contra las decisiones judiciales. De manera general está consagrado en el artículo 29 de la C.P., cuando refiere el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y en el artículo 31 siguiente, cuando indica que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

A pesar que las referidas normas constitucionales son claras en restringir tal principio con sustento en la libertad de configuración legislativa, lo que implica que el derecho a la segunda instancia no es absoluto, tal limitación debe ser clara y su interpretación no generar dobles hipótesis que, en verdad, solo afecten los derechos procesales más íntimos de las partes en medio de una disputa judicial como lo son la defensa y la contradicción.

4.2.- Es claro que la acción de responsabilidad de la controlante o la matriz respecto a la situación concursal de una de sus subordinadas se encuentra dispuesta en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006; sin embargo, no por ese simple hecho, la decisión que la defina debe ser privada de revisión por vía de apelación.

En algunos precedentes proferidos por la Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha definido que el trámite de recuperación y liquidación empresarial goza de cierta característica de inmediatez; lo anterior, en procura de evitar la desintegración económica de las compañías, promover principios como la libertad de empresa e iniciativa privada y, con mayor evidencia, mantener y proseguir esas actividades económicas como extensión natural del derecho a la personalidad jurídica y, debido a ello, han concluido que las acciones judiciales que se encaminen a reintegrar el patrimonio (prenda general de la organización) o evitar su espuria disgregación (para defraudar a los acreedores) contempladas en esa Ley, deben gozar de idéntica característica con fines a permitir cumplir con el propósito principal del régimen de

insolvencia (recuperar al agente económico), de allí que deban ser tramitadas como procesos de única instancia.

Pese a dicho análisis, compartido por la Sala, en momento alguno puede arribarse a la insuperable postura de que toda pretensión promovida dentro del trámite de insolvencia deba atender a juicios sin control vertical, pues hay acciones que escapan del propósito arriba estudiado. Debido a ello, las sentencias detalladamente descritas en el auto objeto de súplica, proponen las acciones de revocatoria y de simulación como trámites anexos que, en verdad, buscan reintegrar el activo y evitar su dispersión en fraude a los acreedores, de tal modo que permiten establecer con certeza qué tiene la compañía para pagar sus deudas, elemento incuestionable de cara a la elaboración de un acuerdo de pago o una liquidación; acciones que además fueron contempladas en los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006 y claramente definidas como accesorias a esta en el artículo 21 del Decreto 1749 de 2011 que reguló algunos aspectos de la primera.

4.3.- Empero, la pretensión de que trata el artículo 61 de la Ley 1116 y que motiva el asunto, esto es, la búsqueda de responsabilidad subsidiaria en la matriz o controlante por el estado de situación concursal en que se vio inmersa la compañía, no se encamina a recuperar activos o establecer a ciencia cierta cuál es el capital real de la compañía que respaldará a los acreedores (principio de universalidad), tampoco a poner en entredicho el estado contable de la solicitante y, por ahí, su posición de reorganizada o liquidada, no. Su finalidad es, por la vía de un claro juicio de responsabilidad civil, procurar que sea la matriz quien solvente *subsidiariamente* los saldos insolutos que no pueda sufragar la concursada, por cuenta que la necesidad de haber ingresado en aquel estado de recuperación tuvo sustento en las determinaciones corporativas de quien, en una posición de gobierno jerárquicamente superior, impuso a la inferior.

La Superintendencia de Sociedades, en sus facultades de fiscalización corporativa, ha indicado al respecto que:

> *" (…) Es así como, tanto el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, como el actual artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, indican que en los eventos en los cuales los activos de la subordinada sean insuficientes para satisfacer las acreencias del deudor dentro de un proceso de insolvencia, la matriz o controlante responderá subsidiariamente por las obligaciones insolutas, responsabilidad que, en ambos casos, debe ser declarada jurisdiccionalmente, dentro del cual la matriz, si es del caso, deberá demostrar que la insolvencia fue ocasionada por motivos o causas distintas a las decisiones que adoptó como controlante de la compañía insolvente (…)"*[2]

Por lo anterior, el criterio sustentado en los fallos de tutela que fueron acogidos por la Ponente, para la Sala Dual, no son aplicables al caso concreto por representar una hipótesis que, aunque gravitó sobre una acción judicial dentro de un trámite de insolvencia, no refiere a la que se invoca en el *sub lite* y, por tanto, no puede emplearse

[2] *Oficios 220-084534 del 24 de septiembre de 2012; 220-024904 del 08 de marzo de 2013 y 220-059776 del 27 de abril de 2018.*

analógicamente en perjuicio del derecho de contradicción del convocante.

Aunado a ello, aun cuando en el Decreto 1749 de 2011[3] hace alusión a los procesos accesorios, su artículo 27 en momento alguno definió que la declaratoria de responsabilidad subsidiaria del artículo 61 de la Ley de insolvencias lo sea, pues se supeditó, en exclusiva, a indicar que en tratándose de los procesos de reorganización que conjuntamente promuevan los grupos de empresas, el estado de control no requerirá declaración previa o inscripción anticipada en el registro mercantil, pues dicho carácter *"control"* es propio del concepto de grupos empresariales que acuña el mismo Decreto y que históricamente ha definido ese modelo de empresariado.

4.4.- En ese orden de ideas, no resultaba ajustado limitar la apelación a un juicio que, por su naturaleza abreviada (hoy verbal), era susceptible de ese medio de impugnación judicial, por lo que se concluye que la decisión suplicada será revocada para que, en su lugar, se de continuidad al trámite ante esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Civil -Sala Dual- del Tribunal Superior de Bogotá D. C.,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 24 de marzo de 2020 por la Magistrada Sustanciadora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Sin condena en costas, ante la prosperidad del recurso.

TERCERO: Ordenar la devolución del expediente al Despacho de la Magistrada Clara Inés Márquez Bulla, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

[3] *Que reglamentó algunos artículos de la ley 1116 de 2006*